

ТЕКСТЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИИ



Цезары Мик

**ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА**



ХЕЛЬСИНКСКИЙ ФОНД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Цезары Мик

**ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРАВО В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА**

ВАРШАВА 2005

Научный редактор русскоязычного издания: проф. Александр Горелик

Перевод с польского: Ирина Багаева-Урбанек

Настоящее издание публикуется в рамках программы:

*Organizing and Empowering the Human Rights Movement
for Civil Society in the CIS*

Спонсируемой:

Open Society Institute

Ford Foundation

John and Catherine T. MacArthur Foundation

© Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, Polska

ISBN 83-87300-50-0

Издание II

Тираж 250 экз.

Подготовлено к печати: Nadhi

В наше время права человека охраняются одновременно международным и внутригосударственным правом. При этом международному праву принадлежит особая роль. Это происходит отнюдь не потому, что международное право полностью гарантирует права человека, и даже не потому, что ему принадлежит верховенство при их защите, — как раз наоборот. Как правило, права человека охраняются полнее внутренним правом и ему безусловно принадлежит верховенство в этой сфере. Особое место международного права в общем процессе защиты прав человека объясняется тем, что именно оно устанавливает минимальный перечень прав и свобод, которые должны быть гарантированы всеми государствами-участниками международной защиты прав, оно определяет принципы, условия и порядок отхода от минимальных требований и формирует некое общее видение прав человека. Таким образом, международное право служит ограничителем свободы государств прежде всего в сфере установления отношений между публичной властью (органы государственной власти и местное самоуправление) и подвластными ей гражданами. Международное право делает то, чего внутреннее право не сделало или что сделало небезупречно: подвергает контролю действия публичной власти с целью исключить произвол.

Международное право в области защиты прав человека создает сложную защитную структуру. С формальной точки зрения она складывается из международно-правовых источников, норм и обязательств. Ее материальную сторону представляют общая концепция прав человека и стандарты их соблюдения, определяющие содержание отдельных прав и свобод личности. Принимая во внимание вступительный характер настоящей статьи, мы ограничимся в своих рассуждениях основными положениями на тему международных источников права, норм и обязательств, а также ключевых сведений относительно международной концепции прав человека.

I. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

1. Международное право в области защиты прав человека — составная часть общего международного права, а это значит, что в обоих случаях хотя бы потенциально источники права должны быть одни и те же. В принципе, известны три источника общего международного права: международный договор, международный обычай и общие принципы права. Иногда сюда добавляются решения международных организаций и конференций. Кроме того, подчеркивается, что дополнительными средствами при определении содержания международных норм могут служить решения международных инстанций (судебные и арбитражные), а также доктрины выдающихся специалистов по публичному международному праву. Здесь может возникнуть вопрос: какое значение имеют отдельные источники права в области защиты прав человека и как они связаны между собой? Рассуждения на эту тему начнем с международного договора.

2. В самом общем виде можно сказать, что международный договор — это любое соглашение, по крайней мере, между двумя субъектами международного права, регулируемое международным правом¹. Существо международного договора, таким образом, связывается не с его формой, а с тем фактом, что компетентные представители, по крайней мере, двух субъектов международного права делают согласованные заявления о своей воле. Форма же может быть как устная, так и письменная (при этом нужно иметь в виду, что установление существования и содержания устного договора куда труднее, чем письменного). Договор (в польской номенклатуре его называют трактатом) является родовым понятием для письменных соглашений независимо от того, под каким конкретным названием они фигурируют.

¹ J. Gilas: Prawo międzynarodowe, Toruń 1995.

Основные вопросы, связанные с международными договорами типа трактата, регулируются сегодня прежде всего Венской конвенцией о праве договоров от 23 мая 1969 г. (в дальнейшем ВКПД), которая имеет обязательную силу также и в Польше².

В области прав человека значение имеют именно письменные договоры, а не устные соглашения. Таковыми являются Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Европейская социальная хартия 1961 г., Американская конвенция прав человека 1966 г. или Африканская хартия прав человека и народов 1981 г.³, Арабская хартия прав человека 1994 г.⁴ или Конвенция СНГ о правах человека и основных свободах 1995 г.⁵

Все договоры общего международного права, в том числе и по правам человека, принято упорядочивать в соответствии с определенными критериями. Так, например, в зависимости от того, на какую территорию распространяется обязательность договоров, они делятся на имеющие всеобщий характер (см. вышеупомянутые пакты 1966 г. или Конвенцию о правах ребенка 1989 г.), региональные и субрегиональные (см. Конвенцию Совета Европы 1950 г., Американскую конвенцию 1969 г. или Африканскую хартию 1981 г.). Двусторонние договоры, как правило, не ограничиваются исключительно правами человека, а затрагивают также вопросы сотрудничества, добрососедских отношений и т.д. Тем не менее в двусторонних договорах можно найти в более или менее общей формулировке положения по защите прав человека (например, национальных меньшинств). Защита прав человека может быть также оговорена в положениях, определяющих условия сотрудничества или экономической помощи. По своему предметному содержанию договоры по правам человека делятся на договоры общего характера (например, вышеупомянутые пакты и региональные конвенции) и специальные (например, Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.,

² Dz.U. 1990, №74, публ. 439, приложение.

³ Трактаты, за исключением конкретно обозначенных случаев, цитируются по сб. *Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, opr. B. Gronowka, N. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1996.*

⁴ Текст: "Revue Universelle des Droits de l'Homme" vol. 7 1995, а 4-6, 212-214.

⁵ Текст: "Human Rights Law Journal" vol. 17, 1996, № 3-6, 159-162.

Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины⁶). В зависимости от охвата субъектов прав человека можно выделить договоры широкого охвата (например, пакты и региональные конвенции) и специализированные (например, Конвенция о правах ребенка 1989 г.). Существуют также договоры смешанного типа (например, Конвенция ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин 1979 г., Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств 1995 г.). И наконец, в зависимости от срока действия соглашений следует упомянуть договоры, действующие как в мирное время, так и во время вооруженных конфликтов (например, пакты, региональные конвенции) и такие документы, которые действуют только в период военных конфликтов и положены в основу международного гуманитарного права (в частности, четыре Женевские конвенции о защите жертв военных конфликтов 1949 г. совместно с двумя дополнительными протоколами 1977 г.)⁷.

При анализе приведенных классификаций следует иметь в виду, что все они, кроме, может быть, последней, служат прежде всего для упорядочения материала и не имеют принципиального значения. Поэтому было бы ошибкой разбивать внутреннее единство международной защиты прав человека только из-за того, что конкретные права упоминаются в том, а не ином правовом документе (см. дальнейшие рассуждения о правах человека, пункт IV).

3. Вторым важным источником международного права является обычай. Под обычаем принято понимать согласованную и длительную практику государств (так называемый *usus*), которой сопутствует убеждение (правовое сознание), что она представляет собой обязательное право (*opinio iuris sive necessitatis*). Таким образом, практика становится доказательством (выражением) существования права. Однако правом становится только такая практика, относительно которой существует убежденность, что она обязательна для всех участников. А это значит, что всякое поведение, отходящее от принятой практики, будет считаться не проявлением иной, столь же обязательной практики, а нарушением права. Дело будет обстоять иначе лишь в том

⁶ Текст: *Europejskie standardy bioetyczne*, opr. T. Jasudowicz, Toruń 1998.

⁷ Тексты, связанные с международным гуманитарным правом: *Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów*, opr. M. Fleming, Warszawa 1991.

случае, когда в результате противного поведения (*actus contrarius*) ранее принятая практика изменится или отомрет (*desuetudo*). Международное обычное право может иметь всеобщий характер, а также быть региональным и даже двусторонним.

В области прав человека на современном уровне развития права обычай, общепринятый в особенности, не играет серьезной роли. Ведь права человека с трудом пробивались к сознанию власть имущих, да и к самому международному праву. Они прокладывали себе путь не через практику конкретных государств, которой было свойственно скорее недостаточное соблюдение прав и свобод, а посредством договоров и резолюций международных организаций, подчеркивающих необходимость возврата к уважению прав человека и устанавливающих круг прав, которые должны быть признаны (вначале такую роль играла Всеобщая декларация прав человека 1948 года, принятая Генеральной Ассамблеей ООН).

В настоящее время обычай служит прежде всего дополнительным средством защиты прав человека. При этом он имеет большее значение не на всеобщем, а на региональном уровне, поскольку легче, полнее и быстрее можно создать общую практику в отношениях между государствами, которые роднят подобная правовая культура, общий стиль мышления и действий⁸. Тем не менее, следует подчеркнуть, что сегодня можно говорить о том, что из всеобщего обычного права вытекает принцип уважения прав человека и основных свобод. Существует также точка зрения, что, по крайней мере, некоторые безоговорочно защищаемые права и свободы могут считаться частью всеобщего обычного права (например, свобода от пыток)⁹. Есть и такое мнение, что составной частью обычного права является Всеобщая декларация прав человека 1948 г.

4. Главным источником международного права считаются также общие правовые принципы. В международном правоведении нет полного единогласия в понимании этого источника. Одни считают,

⁸ Таким образом, обычное право в области прав человека имеет шансы получить развитие в первую очередь в Латинской Америке, а также Европе и частично в Африке. Его шансы менее очевидны в Азии, которая, по всей видимости, является континентом с наибольшим культурным разнообразием.

⁹ С. Mik: *Powszechnie uznanie a imperatywne normy praw człowieka*, "Państwo i Prawo" (далее: PiP) 1989, № 9, 54-64.

что эти принципы выводятся из уже действующего международного права (исходные положения либо некоторые обобщения), другие — что сюда относятся принципы, общие для международного права и правовых систем отдельных стран, а третьи — что общие принципы международного права являются проявлением универсальных закономерностей юридической мысли или относятся к сфере нравственности. Наиболее правильной, по нашему мнению, следует считать точку зрения, согласно которой под общими понимаются правовые принципы в определенной отрасли международного права, разделяемые двумя или более государственными правовыми системами (например, в отрасли гражданского, уголовного или морского права).

В доктрине международного права общими правовыми принципами являются чаще всего положения процессуального порядка (например, принцип приобретенных прав, принцип, запрещающий возбуждать и проводить разбирательства по делу, в котором на ту же самую тему и в отношении тех же самых лиц уже был вынесен окончательный приговор). Тем не менее, нам кажется, что такие принципы могут иметь и материальный характер.

В области прав человека общие принципы международного права, подобно обычному праву, не играют большой роли. Это объясняется самой сущностью данного источника права, связанного с необходимостью сравнительного анализа различных правовых систем отдельных государств. Тем не менее, они могут быть хорошим дополнением договорной защиты прав, способствовать созданию более совершенных, полных и эффективных гарантий их соблюдения, а также уточнению действующих международных норм. При этом одинаково важными будут как процессуальные (например, принцип эффективности, недопустимости злоупотребления правами, приобретенных прав), так и материальные принципы (например, принцип уважения прав собственности иностранцев).

5. Некоторые считают, что источником международного права являются также резолюции международных организаций или конференций¹⁰. Следуя англоязычной традиции, его принято называть *soft law* (мягкое право). Сторонники этой точки зрения убеждены, что источники права различаются по степени своей обязательности.

¹⁰ R. Bierzanek: “*Miękkie*” prawo międzynarodowe, “Sprawy Międzynarodowe” 1987, № 1.

Относительность такого подхода вызывает, однако, заслуженную критику, указывающую на то, что подобные рассуждения наносят вред международному праву, делая его менее четким. В то же время подчеркивается, что резолюции международных конференций и организаций могут быть полезны в законотворческой деятельности, а также при внесении изменений или уточнений в международное право¹¹. Они также могут функционировать в международных отношениях самостоятельно и иметь фактическую обязательную силу на основании добровольного соблюдения государствами¹².

Резолюции международных организаций и конференций (в особенности, пленарных заседаний общих организаций, таких, как ООН, Совет Европы и др., а также ОБСЕ) выполняют важную задачу в области прав человека. Во-первых, они формируют международные концепции прав человека (исключительную роль сыграла здесь Всеобщая декларация прав человека 1948 г., которая считается идеологическим манифестом прав человека). Во-вторых, резолюции подготавливают почву для принятия договоров — они дают создателям договоров материал для обсуждения и в зародыше намечают содержание будущего договора (именно в таком качестве выступила Всеобщая декларация прав человека по отношению к Пактам ООН 1966 г. или Декларация о правах ребенка 1959 г. по отношению к Конвенции о правах ребенка 1989 г.). В-третьих, международные резолюции могут способствовать возникновению и развитию обычного права (в тех случаях, когда большой период времени отделяет принятие резолюции от вступления в силу соответствующего договора, см. Всеобщую декларацию прав человека и Пакты ООН). В-четвертых, резолюции могут действовать как рекомендованные, но формально не обязательные стандарты, либо дополнять и развивать обязательные стандарты в тех областях или на тех территориях, где создание или введение в жизнь правовых стандартов чрезвычайно затруднительно или вообще невозможно (например, вопросы защиты прав человека, в том числе национальных меньшинств, в рамках СБСЕ/ОБСЕ). И, наконец, в-пятых, резолюции могут способствовать

¹¹ K. Skubiszewski: *Rola niewiążących uchwał normatywnych w prawotwórstwie międzynarodowym*, PiP 1986, № 1.

¹² R. Ida: *Formation des normes internationales dans un monde en mutation: critique de la notion de soft law* [В:] *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement*. Melanges M. Viralli, Paris 1991, 337.

лучшему соблюдению правовых и политических обязательств уже тем фактом, что в них документируются и осуждаются нарушения прав и свобод.

6. При определении содержания правовых норм в качестве вспомогательных средств используются решения и постановления международных контрольных органов и документы международного права. Хотя они и считаются вспомогательными, их практическое значение может быть весьма существенным, и поэтому их принято называть вспомогательными источниками международного права.

Что касается юрисдикции международных контрольных органов, принципиальное значение для толкования и применения международного права имеют решения международных и арбитражных судов. Первые из них имеют, как правило, характер постоянно действующих инстанций. Сюда относятся всеобщие и региональные суды как общей юрисдикции, так и специальные. В настоящее время самым важным международным судом является Международный Суд ООН с местопребыванием в Гааге. Это один из главных инструментов ООН. Арбитражные суды имеют временный характер и создаются для рассмотрения конкретных дел.

В области прав человека преобладающую роль играют решения постоянно действующих судов. Как и в международном праве вообще, особенно важны здесь решения Международного Суда. Однако они принимаются довольно редко и в них рассматриваются, как правило, общие принципы. Из-за этого на практике большее влияние имеют решения специальных контрольных органов. Такие органы создаются, главным образом, на основании международных договоров по правам человека, а не соглашений более общего содержания. В качестве примера можно привести Комитет ООН по правам человека, созданный на основании Пакта о гражданских и политических правах, а также Европейскую Комиссию и Европейский Суд по правам человека¹³, образованные на основе Конвенции 1950 г.¹⁴. Международные органы, осуществляющие контроль за уважением прав человека, не всегда

¹³ A. Bisztyga: *Europejski Trybunał Praw Człowieka*, Katowice 1997.

¹⁴ Судебные решения европейских органов обсуждаются в целом ряде трудов: M. A. Nowicki: *Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa*, Warszawa 1998; T. Jasudowicz: *Orzecznictwo strasburskie. Zbiór orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990-1997*, t. I-II, Toruń 1998.

являются судами. Часто это квазисудебные органы, а их решения — *par excellence* не приговоры, а всего лишь рекомендации (см. мнения Комитета ООН по правам человека¹⁵). Тем не менее, можно с полной ответственностью утверждать, что они играют не менее важную роль, чем судебные решения, и что с их постановлениями нужно считаться в такой же степени, что и с решениями международных судов. В то же время решения арбитражных организаций не играют существенной роли в области прав человека.

Другим вспомогательным источником служат взгляды известных правоведов-международников. Это объясняется тем, что международное право до сих пор не было полностью кодифицировано и в связи с этим представители юридической науки обязаны систематизировать и развивать накопленные правовые знания. Доктрина международного права — и это касается не ее одной — не представляет собой нечто монолитное. Она строится либо в соответствии с определенной общей идеологией или философией, либо по школам или основным направлениям в правовом мышлении. Среди последних следует отметить естественное направление, для которого источником всякого права является Всевышний или Природа, и позитивистское направление, в соответствии с которым источником права может быть только нечто положительное (позитивное), созданное благодаря человеку и его разуму.

Самыми влиятельными в международном праве в области защиты прав человека является англосаксонская (английская, американская и немецкая) и французская доктрины. Важное место занимают также австрийская, бельгийская, голландская и итальянская доктрины. По всей видимости, главенствующее положение занимают позитивистское и либеральное направления. Польской доктрине прав человека еще не удалось создать собственной научной школы. Тем не менее следует отметить, что исследования по защите прав человека проводятся как с философской и теоретической позиции (М. Пеховяк), так и с позиции международного права (А. Михальская, П. Дарановский, К. Джевиский, Т. Ясудович, Б. Гроновская, Ц. Мик, Ф. Биштыга), конституционного права (Б. Банашак, Л. Висьневский), а также

¹⁵ Cp. P. Daranowski: *Międzynarodowa ochrona praw obywatelskich i politycznych. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych*, Łódź 1993; A. Michalska: *Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo*, Warszawa 1994.

некоторых частных наук (уголовная процедура — П. Хофманьский, Б. Гроновская; гражданское право — М. Сафьян). Нужно также упомянуть, что в некоторых высших учебных заведениях существуют кафедры прав человека (например, Кафедра прав человека и европейского права в Университете им. Николая Коперника в Торуни) и что выходят журналы, посвященные главным образом правозащитной тематике, например, *Торуньский ежегодник прав человека и мира*, или *Тетради по гуманитарным наукам. Права человека*.

7. Итак, ведущее место в международной защите прав человека занимают общие и региональные (многосторонние) договоры. Роль вспомогательных источников (по юридическому уровню равных договорам) играют обычай и общие принципы международного права. Они дополняются резолюциями международных организаций и конференций (ОБСЕ), в которых содержится целая сеть рекомендуемых стандартов, а также решениями международных судов и доктриной прав человека. Исходя из вышесказанного, мы в своем дальнейшем анализе будем заниматься, в основном, международными договорами.

II. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

8. Главным элементом источников международного права являются правовые нормы. Под нормой международного права понимается “правило поведения в международных отношениях, лежащее в основе обязательств и требований и одновременно стремящееся к выражению таких ценностей, как эффективность, обоснованность и уважение”. Освещение проблематики норм международного права в области защиты прав человека позволит познакомиться с правилами поведения адресатов указанных норм на международном уровне. Кроме того, мы сможем определить взаимоотношения международных норм между собой и по отношению к внутренним нормам.

Начнем с перечисления видов международных норм и описания их взаимоотношений. В правоведении международные нормы классифицируются на основе разных критериев. Для большей четкости ограничимся лишь некоторыми из них.

9. Наиболее принято деление на общие и специальные нормы, причем последние включают и региональные, и двусторонние нормы. Иначе говоря, в отличие от внутреннего права, в международном праве отсутствует иерархия норм в территориальном смысле. Поэтому общепринятая норма не делает ничтожной частную норму, если только не является по отношению к ней более поздней, не противоречит частной норме по содержанию, а адресат у обеих норм — один и тот же субъект международного права (ср. ст. 30 ВКПД). Это означает также, что частная норма, соответствующая вышеуказанным требованиям, может, в отношении конкретных адресатов, сделать недействительной общепринятую норму. Наиболее существенно, однако, чтобы создание и тех и других норм осуществлялось в соответствии с международным правом (его безоговорочно обязательными принципами и нормами).

Разделение на общепризнанные и частные нормы действует и в сфере прав человека. Так же, как и в случае общего международного права, соотношение между общим и частным должно определяться в категориях норм, а не источников права. При этом в каждой конкретной области важно не столько показать, что общепризнанная норма может лишить важности частную норму, сколько — в целях обеспечения максимальной защиты человеческой личности — доказать, что обе нормы не исключаются, а взаимодополняются и что существующие между ними различия можно устранить с пользой для человека.

Прежде чем мы представим этот вопрос в отношении прав человека, нужно отметить, что, как и во внутреннем законодательстве, в международном праве существует разделение на материальные нормы (непосредственно регулирующие международные отношения), процессуальные нормы (регулирующие порядок действий адресатов) и нормы о компетенции (определяющие правомочность определенного поведения). В контексте взаимоотношений между общепризнанными и частными нормами нужно обратить внимание прежде всего на отношение между материальными и процессуальными нормами.

10. Итак, говоря о материальных нормах (непосредственно регулирующих права и свободы), следует обратить внимание на то, что существует принципиальное сходство между общепризнанными и региональными нормами по правам человека (ср. нормы Пактов 1966 г., Европейской конвенции о правах человека 1950 г. и Евро-пейской социальной хартии 1961 г.). Однако бывают и расхождения. Иногда они несущественны, в других случаях их удастся устранить¹⁶.

Первая ситуация имеет место, прежде всего, в тех случаях, когда права охраняются одним видом норм — общепризнанными, но не региональными, или наоборот. Так, например, право собственности охраняется ст. 1 Дополнительного протокола к Европейской конвенции 1952 г., но не оговаривается в Пактах о правах человека. Культурные же права гарантируются ст. 14 Пакта об экономических, социальных и культурных правах, но отсутствуют в европейских документах. В общем можно сказать, что неустранимые различия — это принципиальные различия, которые контрольный орган не

¹⁶ C. Mik: *Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka*, Toruń 1994, 20-25.

в состоянии устранить, несмотря на всю свою доброжелательность и компетенцию по применению договора.

С устранимыми расхождениями мы имеем дело в тех случаях, когда данное право в принципе гарантируется и теми, и другими нормами (например, право на свободу и безопасность — ст. 9 и 10 Пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции), но в конкретной интерпретации между нормами существуют различия (например, ст. 10 Пакта гарантирует право на гуманное обращение лицам, лишенным свободы, включая особую защиту заключенных, чего не формулирует четко Европейская конвенция, которая, в свою очередь, защищает не только лишенных свободы в связи с уголовным разбирательством, но также и тех, чья свобода была ограничена в результате действия правил об охране от инфекционных заболеваний, о лишении свободы психически больных, алкоголиков, наркоманов и бродяг). Эти различия можно устранить, а международный контрольный орган располагает полномочиями и компетенцией для того, чтобы сделать это. Устранение осуществляется посредством соответствующего толкования нормы, детализирующего или расширяющего ее содержание (так было ликвидировано различие между ст. 9 и 10 Пакта и ст. 5 Конвенции).

Иногда, и этим не следует пренебрегать, предпочтение получают частные материальные нормы. Формально это предпочтение выражается в виде оговорок или заявлений о толковании к договорам из области прав человека (см. рассуждения об обязанностях, п. III). Оговорки и заявления о толковании обязывают международные контрольные органы принять такую интерпретацию общепринятой нормы, которая будет соответствовать данной региональной норме. Так, например, Франция сделала оговорку, что ст. 19, 21 и 22 Пакта о гражданских и политических правах должны интерпретироваться согласно ст. 10, 11 и 16 Конвенции и что при этом ст. 19 Пакта не будет препятствовать государственной монополии на радиовещание и телевидение.

11. Что касается отношений между общим и региональным правом с точки зрения процессуальных норм, надо отметить, что каждое из них располагает в области прав человека собственными процессуальными нормами. Эти нормы, в принципе, не связаны друг с другом и создают особые международные процедуры рассмотрения жалоб

в случае нарушения прав и свобод. Тем не менее, особенно в таких случаях, когда отдельное лицо может самостоятельно обращаться (с жалобой) в различные международные организации, возникает необходимость определить отношения между этими процедурами¹⁷.

С точки зрения прав человека особое значение имеют отношения между процессуальными нормами Факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических правах 1966 г. и ст. 19 и др. Европейской конвенции 1950 г. Дело в том, что в рамках каждого из этих договоров *prima facie* приняты разные подходы. Так ст. 5 § 2а Протокола устанавливает, что Комитет ООН по правам человека не может рассматривать никаких сообщений от лиц, если этот же вопрос рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования (так называемый принцип *pendente lite*). Это означает, что если какой-либо вопрос уже рассматривался другим международным органом и процедура его разбирательства этим органом закончена, то Комитет может принять этот вопрос к рассмотрению. В рассмотрении может быть отказано, только если вопрос еще находится в стадии разбирательства в рамках другой международной процедуры (например, Европейской конвенции о правах человека).

Иначе представлена эта проблема в ст. 27 § 1в Европейской конвенции, где европейским органам запрещается рассмотрение дел, которые уже разбирались в рамках какой-либо другой международной процедуры разбирательства или урегулирования. При этом данный запрет рассматривается как запрет *ne bis in idem procedatur* (запрет нового ведения дела в отношении тех же самых субъектов и по этому же вопросу).

Несмотря на различия между процедурами в Пакте и Конвенции, на практике оно, по всей видимости, не имеет большого значения. Это, в особенности, касается Комитета, который до сих пор рассматривал или признавал подлежащими рассмотрению только такие жалобы, которые проходили через Европейскую Комиссию и были формально закончены либо как неуместные, либо в результате изъятия петиции, хотя она и была оценена как приемлемая. Не известен ни один случай

¹⁷ T. Zwart: *The Admissibility of Human Rights Petitions. The Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee*, Dordrecht – Boston – London 1994 173-185.

рассмотрения Комитетом такого дела, которое закончилось решением по существу в рамках другого международного органа, даже если решение было не в пользу истца.

При рассмотрении отношений между процессуальными нормами возникает еще одна проблема — это вопрос предпочтения частных процессуальных норм. Общий принцип сводится к тому, что истец может свободно решать, какие нормы он выбирает — общепризнанные или региональные. Иногда, однако, эта свобода ограничивается или даже исключается. Так обстоит дело также и в случае споров между государствами: в ст. 62 Европейской конвенции говорится, что если данное право защищается как Конвенцией, так и другими международными инструментами, допустимо пользоваться исключительно процедурой, предусмотренной в Конвенции. В случае индивидуальных жалоб государства, в особенности члены Европейской конвенции, могут ограничить свободу выбора частными лицами той или иной процедуры посредством представления оговорок, исключающих в отношении какого-либо права возможность пользоваться процедурами Пакта, если данное дело уже было или является в данный момент предметом разбирательства европейских органов (так поступили, например, Дания, Франция, Испания, Исландия, Люксембург, Норвегия, Швеция, Италия).

12. В международном праве существует разделение на нормы обязательные безусловно (нормы *ius cogens*) и относительно (нормы *ius dispositivum*). ВКПД представляет первые из них как нормы общеобязательного международного права, принятые или признаваемые международной общностью государств в целом. Какие бы то ни было отклонения от них допускаются только по единой воле международной общности государств (ст. 53). Каждый договор, противоречащий существующей норме *ius cogens*, не действителен с самого начала и целиком (ст. 53, последнее предложение), а договор, противоречащий новой норме *ius cogens* неэффективен (ст. 64). Все прочие нормы обязательны относительно.

В международном праве нет перечня безоговорочно обязательных норм, а их существование и функционирование иногда ставится под сомнение. Тем не менее, в сознании как правоведов, так и судей мысль о существовании таких норм укореняется все больше. Так, на их тему без обиняков высказывается Международный Суд ООН, он *de facto*

признает в своем решении по делу «Военная и квазивоенная деятельность США на территории и против Никарагуа от 27 июня 1986 г.», что такой характер имеет норма, запрещающая угрозу силой или ее применения, изложенная в ст. 2, п. 4 Устава ООН)¹⁸.

Как в общем международном праве, так и в области защиты прав человека нет однозначно сформулированного перечня безусловно обязательных норм. С некоторым упрощением можно сказать, что поскольку таковыми являются нормы общеобязательного права, от которых не допускаются какие бы то ни было отступления, статус *ius cogens* может принадлежать нормам, находящимся под охраной в ст. 4 § 2 Пакта о гражданских и политических правах. Иногда указывается, что — вопреки определению, содержащемуся в ВКПД, — региональные нормы, соответствующие ст. 4 § 2 также могут иметь характер безусловно обязательных (ст. 15 § 2 Европейской конвенции, ст. 27 Американской конвенции), если не отходят от ст. 4 § 2¹⁹.

13. Международное право прежде всего регулирует международные отношения. Однако в последнее время все чаще наблюдается возврат к идее универсального воздействия международного права, включая внутригосударственные отношения. Эта тенденция особо ощущается в контексте прав человека. И поэтому очень важно определить, как соотносятся между собой международные и внутренние нормы.

В международном правоведении это до сих пор очень спорный вопрос. Поначалу отношение международного права к внутреннему пытались представить как отношение двух правовых систем. При этом с точки зрения одних, так называемых дуалистов (Anzilotti, Triepel), эти системы настолько отличались друг от друга, что для их применения не существовало какой бы то ни было общей плоскости. А это значит, что не было поводов для конфликтов между международными и внутренними нормами. По мнению других, так называемых моноистов (Kelsen, Verdross), международное и внутреннее право создают

¹⁸ ICJ Rep. 1986, §189, 190, 100-101. Cp. W. Czapliński: *Problematyka źródeł prawa międzynarodowego wyroku MTS w sprawie Nikaragui*, PiP 1988, 11, 85-96.

¹⁹ Cp. T. Jasudowicz: *Administracja wobec człowieka*, Toruń 1996, 31; idem: *Determinanty międzynarodowo chronionej substancji praw człowieka w systemie uniwersalnym i europejskim (na tle nauczania prof. Anny Michalskiej)* [в:] *O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej*, T. Jasudowicz, C. Mik (red.), Toruń 1996, 101-102.

нечто единое; их единство базируется на основной норме, принимающей вид международного правила *pacta sunt servanda*. По этой концепции международное и внутреннее право были логично связаны по принципу, согласно которому нормы более низкого уровня выводятся из норм более высокого ранга, причем верховенство нормы зависело от субъектной принадлежности законодателей. В результате могли возникать конфликты между международным и внутренним правом, причем первое, как правило, брало верх.

Такой идеологический подход, за которым, правда, стояла некая философия мышления о международном праве, был далек от действительности и практических потребностей. Поэтому в настоящее время преобладают два иных подхода к проблематике взаимоотношений между международным и внутренним правом — технический и функциональный, причем последний не является предметом наших рассуждений²⁰. Сторонники технического подхода исходят из того, что в конкретных правовых системах действуют определенные технические приемы, связывающие международное право с внутренним. В первую очередь, таким приемом следует считать рецепцию.

Рецепция представляет собой переход международных норм во внутренние, их восприятие внутренней правовой системой. Другим способом, которым государство санкционирует применение норм международного права, является трансформация, которая может быть общей и частной. В первом случае должна существовать внутренняя норма (как правило, конституционная), регулирующая критерии, при соблюдении которых международная норма становится внутригосударственной. Трансформация имеет место каждый раз в тех случаях, когда происходит единичное включение международных норм (а в особенности их комплексов в виде договора) во внутреннюю правовую систему. Это происходит на основании внутренних норм, регулирующих особую процедуру включения (выражение согласия на трансформацию, обнародование норм) и определяющих позицию трансформируемых норм во внутренней системе. В этом случае обнародование имеет конституирующий характер, то есть без выполнения этого требования международные нормы не будут трансформированы во внутренние.

²⁰ Более подробно см. C. Mik: *Porządek międzynarodowy a porządek krajowy w dziedzinie praw człowieka*, PiP 1992, № 11, 4-14.

Существуют также другие методы, а среди них, в частности, отсылка и обязательность *ex proprio vigore*. Отсылка связывается с существованием во внутреннем праве положения, предписывающего применять международные нормы в ситуациях, не урегулированных во внутреннем праве, или в тех случаях, когда внутреннее право противоречит международному. Обязательность *ex proprio vigore*, в свою очередь, означает обязательность в силу самой нормы. Однако успешное применение норм, обязательных согласно этому методу, невозможно без развития и доработки в рамках внутреннего права. При использовании этих методов обнаружение имеет декларативный характер, то есть не создает правового пространства, а просто помогает познать и понять международные нормы.

Следует также упомянуть, что независимо от конкретных методов, часто наблюдается явление самостоятельного использования международных норм. В юрисдикции и в правовой доктрине принято считать, что для того, чтобы международные нормы имели свойство самоисполнимости (*self-executing norms*), они должны соответствовать следующим требованиям: точность, безусловность и полнота (четкое изложение прав и обязанностей).

В области прав человека по-прежнему актуальны как идеологический, так и технический подход к отношениям между международным и внутренним правом. Таким образом, в некоторых государствах, по крайней мере, в сфере прав человека преобладает дуалистический подход (например, Великобритания, Ирландия, Швеция), а в других господствует монизм (Франция, Швейцария). Идеологизирование отношений между внутренним и международным правом не должно отрицательно влиять на практику использования международных норм. В конкретных ситуациях, однако, дуалистический подход может быть использован как решающий аргумент против признания прямого действия международных норм, а монистический подход может послужить обоснованием для необходимости принимать во внимание международные нормы при использовании внутренних норм.

В Польше долгое время господствовал дуалистический подход; было принято ссылаться на него при отказе от непосредственного обращения к нормам по правам человека (в этом духе высказался в своем решении Верховный Суд еще в 1987 г.). В 1989-97 гг. этот подход подвергся постепенной эрозии, что проявилось особенно ярко

в решениях Конституционного и Верховного судов²¹. Конституционный Суд, хотя он и не имеет права анализировать соответствие польского права ратифицированным международным договорам²², упоминает в своем решении от 1992 г. по делу о Законе об охране границ, что в Польше действуют Пакты о правах человека, и поэтому они должны применяться, в том числе и судами, и при этом необходимо исходить из презумпции, что их нормы имеют самостоятельную силу. Аналогичные формулировки имеются в решении Верховного Суда 1991 г. по делу об обратном действии декрета о военном положении, в котором суд постановил, что ст. 15 Пакта о гражданских и политических правах имеет самостоятельную силу.²³

Согласно новой Конституции от 2 апреля 1997 г.²⁴ регламентирование прав личности в Польше базируется на монистическом подходе²⁵. Так, ст. 87 п.1 Конституции гласит, что ратифицированные международные договоры становятся общеобязательным источником права. Кроме того, в ст. 91 говорится, что после обнародования в “Законодательном вестнике” (*Dziennik Ustaw RP*) ратифицированный международный договор становится составной частью национальной

²¹ Хуже обстояло дело в случаях нижестоящих инстанций, в том числе апелляционных. См. курьезы в этой области в 1996-97 гг., приведенные в: W. Czapliński: *Z praktyki stosowania prawa międzynarodowego w polskim systemie prawnym*, PiP 1998, № 2, 82-85.

²² Новый закон о Конституционном суде, принятый 1 августа 1997 г. (Dz.U. 1997, § 102, poz. 643) признает в ст. 2 право суда исследовать соответствие законов и основных правовых актов ратифицированным международным договорам (в случае законов, однако, согласие на ратификацию должно быть выражено в форме закона). Возможен немедленный контроль соответствия международных договоров Конституции до и после ратификации.

²³ J. Łętowski: *Sądownictwo polskie a koncepcja praw człowieka* [в:] *Prawa człowieka — wymiar sprawiedliwości*, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego — “Biuletyn” 1995, № 2, 82-85; P. Daranowski: *Pozycja Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji o ochronie praw i wolności podstawowych w polskim systemie prawnym*, также A. Drzemczewski, M.A. Nowicki: *Europejska Konwencja Praw Człowieka a Polska. Trzy lata po ratyfikacji* [в:] *O prawach człowieka...*, 127-163; P. Daranowski: *Miejsce międzynarodowych umów o prawach człowieka w systemie prawa polskiego i orzecznictwie sądowym* [в:] *Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona*, ред. L. Wiśniewski, Warszawa 1997, 235-257.

²⁴ Dz. U. 1997, № 78, poz. 483.

²⁵ Такая позиция, однако, не бесспорна. См. дискуссию, представленную в нижеперечисленных работах: R. Szafarz: *Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrznym w świetle nowej Konstytucji*, PiP 1998, №1; polemika A. Wyrozumalskiej, PiP 1998, № 4; komentarz A. Wasilkowskiego: *Transformacja czy inkorporacja*, PiP 1998, № 4; odpowiedź R. Szafarz na polemiki: PiP 1998, № 5.

правовой системы и применяется непосредственно, если его применение не обусловлено принятием закона. При коллизии норм международного договора, ратифицированный с предварительного согласия Сейма, имеет приоритетное действие по отношению к закону (п.п. 1 и 2). Подобный статус приобретают также договоры, ратифицированные до вступления в силу Конституции (17 октября 1997 г.), в соответствии со ст. 241 п. 1.

В юридической практике различных государств проявляется интерес к нормам международного права в области защиты прав человека. С технической точки зрения, используются все известные методы, позволяющие связать общее международное право и внутреннюю, национальную правовую систему. В качестве примера общей трансформации можно привести ст. 25 Основного закона ФРГ 1949 г., который устанавливает, что общепринятые правила международного права являются составной частью федерального права, имеют верховенство над законами и непосредственно регулируют права и обязанности жителей ФРГ (см. также ст. 28 § 1 Конституции Греции 1975 г.). Проявлением частной трансформации стало включение Европейской конвенции 1950 г. в Конституцию Австрии 1955 г., при этом Европейская конвенция приобретает конституционную силу (в соответствии с конституционным законом от 1964 г.). Примером отсылки служит ст. 10 п. 2 Конституции Италии 1947 г., по которой положение иностранцев в Италии регламентируется международным правом. В свою очередь метод *ex proprio vigore* нашел применение в ПНР. В настоящее время он приобретает более дословную интерпретацию в пользу самоисполнимости международных норм в области прав человека (*self-executing norms* — см. выше, решение КС 1992 г.).

Как правило, международное право по уровню равняется закону или превышает его, но имеет более низкий ранг, чем конституция. Ранг международного права обычно однозначно регулируется внутренним правом. В этом смысле международные договоры по правам человека ничем не выделяются из общего права и редко приобретают конституционный уровень (например, Австрия). Чаще всего они имеют приоритет по отношению к закону, реже равны закону по рангу (как в ФРГ). В Польше статус международного права еще не получил четкого определения. Тем не менее считается, что он ниже закона.

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

14. Наиболее сложными аспектами международной защиты прав человека являются характер, объем, правила осуществления и результаты нарушений обязательств государств в области международного права²⁶. В принципе, эти обязательства вытекают из договоров и должны иметь характер, свойственный договорным обязательствам в общем международном праве, т.е. быть межгосударственными и взаимными. Однако дело обстоит иначе.

Обязательства государств в области прав человека носят классический характер только в сфере экономических и культурных прав (ср. ст. 2 Пакта об экономических правах, ст. 20 Европейской социальной хартии 1961 г., ст. 1 и 2 Факультативного протокола к Американской конвенции 1988 г.). На данном уровне развития общего международного права их субъектами являются, по существу, только государства-участники договоров (ср., однако, ст. 19 § 6 Протокола к Американской конвенции и Протокол к Европейской социальной хартии 1995 г., в котором устанавливается система коллективных жалоб; этот протокол еще не вступил в силу). Некоторому ограничению подвергся только принцип взаимности, поскольку государства не могут требовать друг от друга подтверждения истечения срока важности договоров, защищающих экономические, социальные и культурные права, даже в случае серьезных нарушений их установлений (ст. 60 § 5 ВКПД).

Совсем иной характер имеют, по всей видимости, обязательства в области политических и гражданских прав. Здесь наблюдается ярко

²⁶ C. Mik: *On the Specific Character of State Obligations in the field of Human Rights*, "Polish Yearbook of International Law" vol. XX, 1993 (1994).

выраженное стремление сделать личность непосредственным субъектом международного права. В договорах, защищающих вышеуказанные права, на государства со всей определенностью возлагаются обязательства в отношении граждан (см. ст. 2 Пакта о гражданских и политических правах, ст. 1 Европейской конвенции о правах человека, ст. 1 Американской конвенции о правах человека и, несколько менее четко, — ст. 1 Африканской хартии) и, кроме того, граждане приобретают право выступать против государства, находясь под юрисдикцией которого они, по их мнению, стали жертвой нарушения прав личности, гарантируемых соответствующим международным договором (см. ст. 1 Факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических правах, ст. 25 Европейской конвенции, ст. 44 Американской конвенции, ст. 55 Африканской хартии).

В этих условиях международные обязательства государства в области гражданских и политических прав приобретают особый, отличный от классического характер, что подтверждается судебными решениями международных органов. В частности, Комитет ООН по правам человека в решении по делу В. Зетелих против Уругвая (1981 г.) подчеркнул, что тезис, согласно которому Пакт и Протокол касаются только государств как субъектов международного права и не могут прилагаться к отдельным лицам, лишается правовых оснований с того момента, как государством была признана компетенция Комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц в соответствии с Факультативным протоколом.

Еще более категорически высказывались региональные органы. Так, Европейская Комиссия по правам человека в своем решении (1961 г.) относительно спора между Австрией и Италией установила, что обязательства, взятые на себя государствами-участниками Конвенции, имеют принципиально объективный характер, так как они скорее предназначены защищать основные права человеческой личности, чем обеспечивать правосубъектность и взаимные права Высоких договаривающихся сторон. Европейский Суд по правам человека, в свою очередь, в решении, принятом в 1978 г. относительно спора между Ирландией и Соединенным Королевством, констатировал, что в отличие от международных договоров классического типа Конвенция содержит нечто большее, чем взаимные обязательства между договаривающимися сторонами. В ней формулируются, помимо сети взаимных двусторонних обязательств, за ее пределами, объективные

обязательства, пользующиеся коллективной гарантией. И, наконец, Межамериканский Суд по правам человека отметил в одном из своих консультативных заключений (1982 г.), что современные договоры по правам человека в целом, а Американская конвенция в частности, не являются традиционными многосторонними договорами, заключенными в целях взаимного обмена правами с взаимной выгодой для государств-участников. Их предмет и цель составляет защита основных прав человеческой личности независимо от гражданства как в отношениях с государством, гражданином которого данное лицо является, так и с любым другим государством-участником договора.

Какой вывод следует из этих решений? Международные органы стараются подчеркнуть, что международные обязательства государств в области гражданских и политических прав распадаются на две категории — обязательства между государствами и обязательства между государством и индивидами, причем эти два вида обязательств не равнозначны. На передний план выдвигаются обязательства: государство — индивиды, а межгосударственные обязательства играют вспомогательную роль как гарант успешного осуществления обязательств первого рода. Необходимо отметить, что в классическом международном праве также известны обязательства: государство — индивиды, однако они не имеют первостепенного значения, а круг лиц, на которых они распространяются, ограничивается, в основном, иностранцами. В представленном выше толковании их носителем становятся, в первую очередь, граждане обязанного государства.

Таким образом, в международном праве существует двойственность правовых обязательств, связанная, главным образом, с функционированием двух групп прав: экономических, социальных и культурных, с одной стороны, и гражданских и политических — с другой. Однако следует подчеркнуть, что различия между ними могут стираться. По всей видимости, этот процесс постепенно углубляется, что нашло отражение в подготовке факультативных протоколов к Пакту об экономических правах по образцу Протокола к Пакту о политических правах и к Европейской социальной хартии.

Обязательства в области прав человека ограничивают свободу государств при регулировании как внутrigосударственных отношений, так и любых других отношений на уровне международного права. При этом нельзя прикрываться принципом невмешательства

во внутренние дела (ст. 2 п. 7 Устава ООН). В то же время обязательства в области прав человека ограничивают свободу государств лишь в таком объеме, который предусмотрен договорами, защищающими указанные права, и лишь в такой степени, которую государства признают либо путем ратификации этих договоров (необратимое ограничение), либо посредством декларации о признании компетенции процедуры международного контроля (обратимое, относительное ограничение). В результате в некоторых областях ограничение может быть предметно широким, но качественно неглубоким, так как единственной формой контроля будут отчеты государств (не только в области экономических, социальных и культурных прав, но и в связи с Конвенцией о правах ребенка и др.). В других случаях ограничение может быть далеко идущим, так как контроль можно проводить по конкретным делам, часто с принятием решения, обязательного для данного государства (в особенности в соответствии с Европейской и Американской конвенциями).

15. Масштаб обязательств можно оценивать с точки зрения территории, на которой они действуют, круга лиц, на которых они распространяются, срока действия и характера регулируемых отношений. Относительно первого из этих критериев следует сказать, что обязательства имеют силу не только на территории данного государства (ср. ст. 29 ВКПД), но и всюду, где действует юрисдикция понимаемого в широком смысле государственного аппарата, т.е. осуществляется суверенная власть (об этом вполне однозначно говорится прежде всего в договорах, защищающих гражданские и политические права — ст. 2 Пакта, ст. 1 Европейской конвенции, ст. 1 Американской конвенции). При обсуждении второго критерия нужно отметить, что межгосударственные обязательства распространяются на все государства-участники, в то время как обязательства: государство — индивиды, с одной стороны, сосредотачиваются на обязательствах государств-участников, а с другой — обеспечивают прежде всего права всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, не исключая иногда и юридических лиц.

Обязательства не имеют обратной силы (ср. ст. 28 ВКПД) и действуют до тех пор, пока остаются в силе договоры, из которых они вытекают. В области прав человека обязательства имеют бессрочный характер, поскольку договоры заключены на неограниченное время. И наконец, в принципе, государства принимают на себя всю полноту

обязательств, вытекающих из договоров, хотя иногда могут модифицировать или ограничивать свои обязательства, используя для этой цели такие инструменты, как оговорки и заявления о толковании.

В соответствии с ВКПД под оговоркой понимается заявление, сделанное в момент подписания договора или окончательного присоединения к нему (например, посредством ратификации), в котором выражается воля государства изменить, ограничить или исключить последствия данной юридической нормы договора (ст. 2 §1). Такое заявление должно получить хотя бы молчаливое согласие других государств. Однако последние могут возражать против оговорки (ст. 20). Возражения могут привести к тому, что данная норма не вступит в силу между государствами-участниками (обязательства будут приняты не в полном объеме) либо договор не войдет в жизнь на уровне взаимных отношений (обязательства не будут приняты — ст. 21).

К некоторым договорам нельзя делать оговорки, это категорически запрещается в тексте самих международных договоров. К другим — можно, но в ограниченном объеме. К третьим, ничего не говорящим на эту тему, оговорки не допускаются в отношении норм, регулирующих объект и цель договора (ст. 19).

Заявления о толковании по существу близки к оговоркам. Их цель — принятие отличной от общепринятой интерпретации конкретных норм, а тем самым изменение или ограничение их последствий.

Международные договоры по правам человека, как правило, обходят молчанием вопрос об оговорках. Это означает, что оговорки допускаются (эта возможность используется довольно часто), но не могут быть направлены против объекта или цели договора, т.е. не могут сводить на нет принципы эффективной защиты прав, а тем более, отменять применение норм, лежащих в основе данного договора (например, положения о степени обязательности договора для государств-участников, устанавливающие минимальные защитные структуры)²⁷. Иногда применяется классический порядок внесения оговорок, как в Пакте о гражданских и политических правах, в других случаях оговорка делегируется (признается недействительной) органами контроля (как например, в рамках Европейской конвенции).

²⁷ P. Daranowski: *Zastrzeżenia do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych*, PiP 1989, № 7.

16. Важную проблему представляют принципы выполнения обязательств. В общем международном праве главенствующую роль играет принцип добросовестного выполнения обязательств (*pacta sunt servanda* — ст. 26 ВКПД). Согласно этому правилу договор становится обязательным для государства, которое окончательно присоединилось к нему, т.е. государство не может отказаться соблюдать положение договора, разве что на это выразят согласие другие государства-участники и сделают это в форме дружественной (а не вынужденной) договоренности. Такой порядок определен самим международным правом. Кроме того, принцип *pacta sunt servanda* требует, чтобы обязательства выполнялись добросовестно. А это, в свою очередь, означает, что государства должны воздержаться от каких-либо действий, которые могли бы свести на нет объект или цель договора (ст. 18). Государства не могут также ссылаться на свое внутреннее право (например, конституцию или содержание решений Верховного Суда) как оправдание отказа выполнять международные обязательства или неполного их выполнения (ст. 27).

Принцип добросовестного выполнения обязательств полностью применяется в области прав человека как в международных отношениях, так и в отношениях «государство – индивиды». При этом следует подчеркнуть, что в области обязательств «государство — индивиды» особое значение приобретает запрет ссылаться на внутреннее право как обоснование нарушений прав человека. Однако этот запрет не имеет безоговорочного характера. Так, например, государства могут приостановить действие правовых гарантий прав личности во время войны или в связи с другой опасностью для общественного порядка (см, в частности, ст. 4 Пакта об экономических правах, ст. 14, 18, 19, 21 и 22 Пакта о политических правах). Государства могут также оправдать свои действия, используя свое право на отступление и охранять свое внутреннее право в рамках институтов оговорок и заявлений о толковании.

Принцип *pacta sunt servanda* касается и государств, и отдельных лиц. Ни одна из сторон обязательств не может злоупотреблять своими полномочиями (соответственно компетенции вмешательства и правосубъектности). Кроме того, государства должны выполнять свои обязательства эффективно (как подчеркивается в решениях международных органов, права должны обеспечиваться реально и практически, а не теоретически и иллюзорно) и достаточно старательно.

При осуществлении обязательств «государство — индивиды» большое значение имеет правило субсидиарности, которое распространяется только на государства. Согласно этому правилу государство должно выполнять свои обязательства добросовестно, но пользуется при этом в большей или меньшей степени свободой выбора средств, с помощью которых оно выполняет свои обязательства во внутренних отношениях. Свобода выбора существенно возрастает, если положения договора неясны или умышленно нечетко сформулированы (это относится, прежде всего, к определению оснований для вмешательства в осуществление прав человека). Таким образом отражением правила субсидиарности становится правило сдержанности международных органов контроля, которые понимают, что первыми доступ к нарушениям прав человека имеют государственные органы (и в первую очередь, суды) и именно на них возлагается обязанность толковать и применять внутренние нормы. Именно к ним обращена также директива уважать пределы свободы внутренних органов. Другим следствием этого принципа является процессуальное требование исчерпать внутренние средства как необходимое условие внесения между-народной петиции.

17. Каждое правовое обязательство имеет юридическое обеспечение на случай нарушения. Эффективным обеспечением служит институт международной ответственности государства. По международному праву государство несет ответственность за действия самого государства (государственного аппарата в широком понимании). В рамках обязательства действовать достаточно старательно государство отвечает также и за то, что им не были приняты меры по предупреждению нарушений или по противодействию нарушениям со стороны третьих лиц, находящихся под его юрисдикцией. Грубые нарушения принято называть международными преступлениями (например, геноцид).

В основном, эта схема находит подтверждение в области прав человека. Государство несет ответственность за действия государственного органа — центрального и местного, административного и муниципального, национального и зарубежного, гражданского и военного. Оно также несет ответственность за действия субъектов, которым государственная власть делегировала исполнение части публичных функций.

Вопрос о привлечении к ответственности возникает в тех случаях, когда было допущено нарушение обязательств, которое можно приписать государству. Нарушение может заключаться в проведении действий, хотя согласно предписанию следовало воздержаться от таковых, и наоборот, нарушением может быть отказ от действий, когда предписано их проведение. Обязательства в области прав человека имеют, в основном, негативный характер, т. е. сводятся к требованию, чтобы государство позволило каждому осуществлять свои права, воздерживалось от вмешательства (например, не применяло самовольного лишения свободы). Органы международного контроля все чаще отмечают, однако, случаи ответственности за нарушение обязательств, предписывающих действия (например, создание правовых гарантий уважения семейной жизни, организация эффективного соблюдения судебных и административных процедур или принятие мер по охране легальной демонстрации от провокаторов).

Нарушения могут быть однократными (например, самовольное лишение жизни), протяженными во времени (например, лишение возможности общения или посещений в отношениях между родителями и детьми), либо имеющими долгосрочные последствия (например, приговор, лишаящий журналиста свободы на ограниченный срок, а права заниматься профессиональной деятельностью на неопределенное время). Государство несет ответственность за всю продолжительность данного действия, за исключением тех случаев, когда ратификация договора состоялась во время протекания действия или именно в этот период государством было сделано заявление о признании компетенции международных органов рассматривать индивидуальные петиции, либо появились новые факты или новые жалобы и возникла необходимость начать отсчет времени заново.

Как правило, государство несет ответственность за фактически состоявшиеся нарушения. Однако в области прав человека в виде исключения могут возникать потенциальные нарушения, связанные с реальным и непосредственным риском нарушения. Такой риск может вытекать как из закона (например, риск применения телесных наказаний с нарушением свободы от унижительного обращения или наказания), так и из административных актов (например, угроза экстрадиции или выселения определенного лица в страну, где ему — согласно объективной и проверенной информации — угрожает серьезная опасность бесчеловечного отношения или пыток).

Для того, чтобы возложить ответственность на государство, нужно доказать его причастность. Органы по международной защите прав человека не углубляются в этот вопрос. По их мнению, достаточно доказать, что ответственность лежит на каком-либо государственном субъекте. Тем не менее, государство располагает возможностью показать либо, что не несет ответственности, ибо отсутствует нарушение, а государство действовало в соответствии с международным правом в области защиты прав человека (например, лишение свободы имело место согласно ст. 5 § 1 Европейской конвенции), либо, что на него вообще нельзя возлагать ответственность (например, нарушение было допущено другим государством или международной организацией, а может быть, сама жертва спровоцировала нарушение).

Нарушение обязательств, как правило, влечет материальный или моральный ущерб. Ущерб может быть возмещен органами самого государства-нарушителя (см. ст. 50 Европейской конвенции). В области экономических, социальных и культурных прав это — единственный возможный в настоящее время путь. В области же политических и гражданских прав, если ущерб возмещен недостаточно или не возмещен вообще, потерпевшее лицо может обратиться в международные органы (ст. 32 и 50 Европейской конвенции, ст. 63 Американской конвенции, такая возможность также вытекает *implicite* из решений и постановлений Комитета ООН по правам человека).

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

18. Вводная информация о правах человека была бы неполной без изложения, хотя бы в общих чертах, концепции прав человека, содержащейся в международных документах. Начнем с нескольких вступительных замечаний.

В международном правоведении ведется спор о том, можно ли говорить о международном понятии прав человека²⁸. Одни правоведы, исходя из того факта, что существуют различные виды правовой и социальной философии, стараются доказать, что такое универсальное понятие отсутствует и выработать его невозможно по причине многообразия региональных концепций, а все, что содержится в международных документах, эклектично по своему характеру. Другие, наоборот, настаивают, что международное понятие прав человека существует и воссоздание его на основе международных документов — вполне реальная задача.

Можно привести целый ряд доводов в подтверждение обеих точек зрения. Тем не менее, нам кажется, что международные органы по правам человека занимают вполне определенную позицию по данному вопросу. Они возражают против чрезмерного идеологизирования прав и свобод и подчеркивают, что существуют объективные международные понятия каждого конкретного права человека и прав человека как таковых. В частности, Межамериканский Суд по правам человека в своем консультативном заключении от 1962 г., выражая мнение по поводу универсализма и регионализма, заявил, что по самой своей

²⁸ Cp. A. Michalska: *O pojęciu praw człowieka*, PiP 1980, №8-9; а так же: *Uniwersalizm praw człowieka* [в:] *Państwo, Prawo, Obywatel. Zbiór studiów ku czci prof. A. Łopatki*, Wrocław 1989, 589-598; M/ Piechowiak: *Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzno-prawne* [в:] *O prawach człowieka...*, 49-71.

природе предмет обсуждения не позволяет четко отделить универсализм от регионализма. Универсализм человеческого рода и универсализм принадлежащих человеку прав и свобод образуют стержень всех международных правозащитных систем. В данном контексте было бы ошибкой проводить различия, основанные на региональном либо нерегиональном характере международных обязательств, гарантируемых государствами, и тем самым отрицать наличие общего стержня у основных стандартов по правам человека.

В подтверждение правильности этой точки зрения можно привести тот факт, что основу всех документов, как обязательных, так и рекомендуемых, основу всех договоров, как общепризнанных, так и региональных, неизменно составляет Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Этот механизм повсюду считается манифестом прав человека и основным источником международной концепции прав человека.

Что представляют собой права человека? Во внеисторическом плане можно сказать, что это “ситуационно расслоенные естественные человеческие возможности, индивидуальные по существу, но детерминированные социально, равные и неотъемлемые, обладающие субъектной, предметной, территориальной, временной, а частично и культурной универсальностью, неизбежные и неизменно вытекающие из присущего человеческой личности достоинства”²⁹.

Источником прав человека является достоинство, присущее человеческой личности³⁰. Это положение однозначно подтверждается, например, в преамбулах к Пактам 1966 г. Достоинство, присущее человеческой личности, необходимо отличать от личного достоинства, ассоциируемого с честью, почетом и уважением. Достоинство, присущее человеческой личности — это нормативная категория, выражающая глубокое убеждение, “что все люди принадлежат к одному и тому же виду и имеют общее происхождение” (Декларация

²⁹ С. Мик: *Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji*, Toruń 1992. Ср. также М. Пиеховиак: *Pojęcie praw człowieka* [в:] *Podstawowe prawa jednostki...*, 5-37.

³⁰ Ср. в частности J. Zajadło: *Godność jednostki w aktach prawa międzynarodowego praw człowieka*, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, № 2; М. Пиеховиак: *Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka*, “Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” 1992 (1993), з. 1; J. Krukowski: *Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki* [в:] *Podstawowe prawa jednostki...*, 38-50.

ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках 1978 г., ст. 1 § 1), а тем самым, что по своим первостепенным биологическим свойствам мы все одинаковы. Убежденность в видовой однородности всех людей, в общей им всем человеческой сущности не противоречит тому, что “люди могут вести различный образ жизни” и не исключает ни “существования различий, основанных на разнообразии культур, среды и истории”, ни “права на сохранение культурной самобытности” (Декларация ЮНЕСКО, ст. 1 § 3).

Достоинство — естественный факт, оно присуще людям от рождения (Всеобщая декларация, ст. 1). Это означает, как утверждает Межамериканский Суд, что права человека — это индивидуальные сферы, которые либо находятся за пределами досягаемости государства, либо государство имеет к ним доступ, хотя и ограниченный (консультационное заключение от 1966 г.). Другими словами, права человека — это естественные права, которые не создаются государством и которыми оно не может никого наделять. Более того, государство не в состоянии лишить человека его прав, но может влиять на внешнее проявление естественных прав, на возможность их осуществления. Правовые акты внутреннего и международного права ограничиваются декларацией прав и свобод, известных законодателям, и дают им правовое обеспечение посредством перевода на язык правовых норм и предоставления процессуальных средств.

Поскольку права человека естественны, они являются также неотъемлемыми (ср. преамбулы к Всеобщей декларации и Пактам). От них нельзя отказаться, их нельзя продать, заложить или завещать. Всеобщность достоинства человеческой личности предполагает универсализм прав и свобод. Это прежде всего эгалитарный субъектный универсализм. “Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах” (ст. 1 Всеобщей декларации). “Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами [...]”. Не должно проводиться никаких различий ни при каких обстоятельствах (ст.2, абз. 1 Всеобщей декларации).

Субъектный универсализм не следует понимать упрощенно. Нужно учитывать, что декларация прав человека касается не абстрактного человека, а конкретных людей, вовлеченных в различные жизненные ситуации. Защитой права на жизнь пользуются прежде всего человеческие существа от момента зачатия и лица, приговоренные к смерти, компетентным судом (ср. ст. 6 Пакта о политических правах) а защитой

права на свободу и безопасность — в первую очередь задержанные, интернированные, насильственно изолированные (ст. 9 Пакта). Таким образом, можно говорить о ситуационной расслоенности прав человека.

Реализация человека в его достоинстве осуществляется через пользование различными благами. Ведь говорится о “праве на” и “свободе от”. Человек нуждается в обеспечении различных благ нематериального характера, например, жизни, свободы, а также материальных — таких, как вознаграждение, социальное обеспечение. В конкретных ситуациях эти блага конкретизируются и приобретают значение. Человек имеет право на каждое благо, которое укрепляет его человеческое достоинство. Иначе говоря, права человека обладают универсальной субъектностью.

Следует иметь в виду, что история человеческого вида продолжается непрерывно. Развивается человеческая мысль, создается новая техника и возможности появления новых благ. Некоторые блага появляются, другие теряют свое значение. Тем не менее, права человека как естественные возможности, т.е. некоторый потенциал, дремлющий в человеке, продолжают существовать независимо от общественной эволюции (Декларация прав человека Совета Европы 1978 г. п. 4) и актуализируются в виде определенных благ в определенное время. Поэтому они обладают временной универсальностью.

Права человека имеют также территориальную универсальность. Всеобщая декларация гласит: “не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете” (ст. 2, абз. 2).

Люди могут отличаться по социальной среде (в которой родились и были воспитаны). Эти различия приобретают форму культурных различий. Международная концепция прав человека исходит, однако, из убеждения, что должен быть принят определенный культурный минимум. Из этого, в частности, следует особое значение, придаваемое праву на справедливое разбирательство в суде (ст. 14 Пакта о политических правах, ст. 6 Европейской конвенции, ст. 8 Американской конвенции, ст. 7 Африканской хартии), которое должно гарантироваться

независимо от того, как суды называются и как организованы в каждой отдельной стране. Поэтому также особая защита обеспечивается семье, независимо от того, как она понимается (ст. 10 Пакта об экономических правах, ст. 23 Пакта о политических правах, ст. 16 Европейской социальной хартии, ст. 8 Европейской конвенции, ст. 17 Американской конвенции и ст. 17 Протокола к ней, ст. 18 Африканской хартии).

Права человека в международном понимании могут быть описаны с точки зрения еще одной характеристики — необходимости. Она не вытекает непосредственно из достоинства, присущего человеческой личности, но является ее прагматическим дополнением. Человек не живет в пустоте. Его жизнь социально детерминирована. Люди входят в различные группы — естественные и искусственные, длительные и временные. В целях регулирования деятельности отдельных лиц, обеспечения минимума безопасности необходимо перенести права человека на почву позитивного права. Рациональный законодатель должен отдавать себе отчет в том, что в наше время успешное управление государством невозможно без провозглашения и защиты прав и свобод, что пренебрежение ими неизбежно будет приводить к злоупотреблениям, кризисам и взрывам общественного недовольства. В этом смысле права человека становятся рационально необходимыми.